



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Expte. nº 3540/2020

Expte. nº CNT 3540/2020
SENTENCIA DEFINITIVA Nº 88779
AUTOS: “R., H. M. C/ ADECCO ARGENTINA S.A. S/ DESPIDO” (JUZGADO Nº 39).

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 30 días del mes de Marzo de 2024, se reúnen la y los señores jueces de la Sala 5, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y el Doctor GABRIEL de VEDIA dijo:

1.- El presente caso se inició ante la demanda del señor H. M. R. en procura de obtener un pronunciamiento judicial que condene a la firma Adecco Argentina S.A., al pago de rubros indemnizatorios, salariales y multas.

El actor fundamentó su pretensión en la ilegalidad del despido, por ser discriminatorio, más allá de encontrarse en período de prueba en el marco del art. 92 bis de la LCT.

Acusó que al haber padecido un accidente laboral que requirió atención por parte de la ART pertinente y el goce de licencia por enfermedad, no debió ser despedido hasta su alta médica.

Invocó como sustento del despido discriminatorio los arts. 178, 182 y 213 LCT.

Ante ello la demandada negó el accidente de trabajo y demás circunstancias, justificando el despido por encontrarse el actor en el período de prueba en el marco del art. 92 bis de la LCT.

La magistrada interviniente, el 14/7/2023, mediante formato digital, resolvió que: “...al hecho que durante el período de prueba el actor padeciere un accidente, no invalida la posibilidad que la ley otorga a ambas partes de extinguir el vínculo laboral, ya que de lo contrario implicaría que necesariamente ante un infortunio laboral, la empleadora quedaría sujeta al mantenimiento del vínculo laboral, anulando de esta manera la posibilidad de la decisión que resguarda el art. 92 bis LCT, ello sin que norma alguna establezca la obligatoria continuidad del vínculo laboral en el supuesto en análisis, tal como fuera reseñado. En virtud de lo expuesto, no encuentro que el despido de autos fuera discriminatorio, y por ende, cabe estar a las previsiones del art. 92 bis LCT, por lo que se impone el rechazo de las pretensiones deducidas con tal sustento (arts. 330, 356, 377 CPCCN, 726 C.C. y Comercial)...”.

Contra tal decisión Adecco Argentina S.A., el 4/8/2023 interpone recurso de apelación vía digital, agravándose de la procedencia de las indemnizaciones, multas de los arts. 2, ley 25323 y 45, ley 25345, más de la orden de entrega del certificado de trabajo.

Fecha de firma: 30/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ETHEL FERDMAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GABRIEL DE VEDIA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE ALEJANDRO SUDERA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JULIANA CASCELLI, SECRETARIA DE CAMARA



#34605535#410006798#20240430123506594

USO OFICIAL

A su vez se queja de la manera de imposición de costas, de la regulación de honorarios a su representación letrada por bajos y de la tasa de interés, con cuestionamiento de inconstitucionalidad de las actas de la CNAT aplicadas.

El señor R., el 7/8/2023 apela en línea, discrepando el rechazo del planteo de despido discriminatorio y de la regulación de honorarios de su representación letrada por apreciarlos bajos.

El perito contable recurre la regulación de sus honorarios por bajos.

Por razones metodológicas, en primer lugar daré tratamiento al recurso del actor y luego al de la demandada.

2.- Los argumentos esgrimidos por el actor al cuestionar la denegatoria del planteo de despido discriminatorio, tendrá recepción favorable en mi voto.

Ello se debe a que los extremos acreditados en autos me llevan a efectuar una lectura distinta a la de mi colega de origen al convalidar el despido directo materializado el 11/4/2019, en el marco del art. 92 bis de la LCT, con sustento en el inciso sexto.

El art. 92 bis en su parte pertinente legisla que: *“El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros TRES (3) meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establecido en los artículos 231 y 232...”*.

A su vez, el inc. 6 de dicho artículo prevé que: *“El trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del período de prueba si el empleador rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso. Queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212”*.

La Magistrada actuante justificó el despido dispuesto por la patronal, por entender que se encontraba dentro del período de prueba, con sustento en que la norma invoca la posibilidad para ambas partes de extinguir el vínculo laboral sin expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna. Al sentenciar de ese modo, advirtió que de los presupuestos fácticos no surgían elementos para hacer lugar a la pretensión de despido discriminatorio.

Sin embargo, del análisis de los extremos acreditados en autos, entiendo que la conclusión del caso debe ser en otra dirección.

Si bien la demandada negó el accidente de trabajo, de la prueba sustanciada surge acreditado su acaecimiento el 22 de marzo de 2019, dentro del período de prueba, pero días antes del despido del actor.

En orden a ello del oficio contestado por Experta ART y la Superintendencia Riesgos del Trabajo – ver sistema lex 100 fechas 29/8/2022 y 17/8/2022, respectivamente -,

Se decide por lo referenciado del accidente de trabajo del actor, fecha del mismo y fecha de





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Expte. nº 3540/2020

alta médica el 27 de junio de 2019, así como de la pericia contable producida en autos – ver sistema lex 100 de fecha 17/11/2022 y aclaraciones de fecha 12/12/2022.

De los propios recibos de haberes acompañados por la empleadora en su responde, surge el pago de salarios por accidente por parte de la empleadora, por lo que cabe tenerlos por ciertos (arts. 330, 356, 377, 386, 396 y 477 CPCCN, 82 LO).

También obra acreditado, el acuerdo arribado por el actor con relación al accidente de marras con la ART en cuestión, homologado en fecha 8/10/2019 (art. 396 CPCCN).

A la luz de tales extremos, la justificación de la misiva extintiva en los términos del art. 92 de la LCT, resulta insuficiente, para considerarla conforme a derecho.

El art. 92 bis no es el único marco jurídico que regula la cuestión.

La calificación jurídica del art 92 bis y de los hechos ventilados, debe efectuarse a la luz de los arts. 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, en el marco del diálogo de las fuentes y de los distintos medios de expresión del derecho.

El primero preceptúa que “Art. 1º: Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho” A su vez el segundo legisla que “Art. 2º: Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. “.

De la lectura de ambos preceptos cabe inferir que no corresponde atender sólo a la literalidad de la ley o a la parcialidad y soledad de un artículo.

Es cierto que el método gramatical es el punto de partida de toda interpretación y el que prevalece si la letra de la ley no ofrece dudas. Pero, este debe ser complementado por los métodos teleológico, sistemático y dinámico, para evitar que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice su espíritu, propósito o finalidad que ha inspirado su sanción. Asimismo debe acudirse a los principios lógicos, como instrumentos que nos permitan revisar si las conclusiones arribadas son frutos de un correcto razonamiento.

Ello no significa apartarse del texto legal. El operador no debe sujetarse, de manera estricta, a las palabras, aislado de una interpretación razonable y sistemática, que desatienda el contexto general y los fines que informan las leyes.

El resultado justo de una controversia judicial impone que la interpretación se ejerza, en busca de equilibrio, de manera razonable y congruente con el sistema jurídico.

USO OFICIAL



La CSJN ha manifestado que a la letra de la ley no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que la concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos; (Fallos: 313:1149; 327:769).

También ha puntualizado que el propósito de armonización de los preceptos de la ley no puede ser obviado por los jueces con motivo de posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 310:940; 312:802).

La aplicación del criterio armonizante expuesto, que surge del mandato constitucional, tuvo expresiones de nuestra C.S.J.N. para la determinación de la validez de una interpretación. Desde siempre se tiene en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849) en la medida en que el resultado de aquélla sea razonable, no se aparte del contexto en que la disposición está inserta, que no sea contradictoria con otras disposiciones, que no se aleje del fin que ha tenido en cuenta el legislador y de otros parámetros concordantes.

En esa inteligencia, al materializar el criterio de interpretación armonizante, no corresponde caer en consideraciones meramente teóricas de las fórmulas e intenciones legislativas. Deben analizarse los resultados que el criterio sustentado por el intérprete provoca en el caso concreto. ‘Los jueces tienen el deber de ponderar las consecuencias sociales de su decisión’ (HOLMES, Oliver Wendell, ‘The path of the Law’, en ‘Harvard Law Review’, vol. 10, pp. 457 y ss; CSJN, ‘Saguir y Dib’, Fallos 302: 1284, con cita de Fallos 234: 482).

Por ello, una de las pautas con mayor grado de prudencia para comprobar el acierto del criterio extraído de la norma es si el mismo conduce a una solución razonable en el caso, puesto que la aplicación de una norma nunca puede hacerse de un modo no razonable que conduzca a resultados injustos.

Nada más injusto que concluir de manera tal, que cierre los caminos del trabajador acreedor de satisfacer su crédito reconocido en sentencia firme, si el ordenamiento jurídico vigente permite una interpretación favorable.

La verificación de los resultados a que conduce la exégesis de una norma y las circunstancias tomadas en cuenta para sancionar la ley, son presupuestos para llegar a su correcto entendimiento (CSJN, ‘Pagano, Héctor Daniel c/ Banco Hipotecario Nacional’, Fallos 305: 1254).

La judicatura al interpretar las disposiciones jurídicas involucradas en una disputa, debe medir la extensión y el alcance de la totalidad que componen el sistema jurídico, que resulten aplicable al caso, en el marco de la razonabilidad.

Esta interpretación razonable debe ser de manera coherente, armonizante y evitando poner las normas en pugna.

Cabe destacar la importancia de verificar el resultado al momento de interpretar normas jurídicas y decidir cuáles se deben aplicar, lo que conduce a puntualizar que la función jurisdiccional en el fuero del trabajo es una justicia de resultado.





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Expte. nº 3540/2020

La judicatura social en general y laboral en particular, no debe decidirse a favor de un medio de interpretación hasta que no ha visto el resultado a que conduce (Gustavo Radbruch, Introducción a la ciencia del derecho, Madrid, 1930. pág. 156).

El principio de razonabilidad no se limita a exigir que sólo la ley sea razonable. Es mucho más amplio. De modo general se puede decir que cada vez que la Constitución depara una competencia a un órgano del poder, impone que el ejercicio de la actividad tenga un contenido razonable.

La razonabilidad, por sobre todo, consiste en una valoración axiológica de justicia que nos muestra lo que se ajusta o es conforme al valor y mandato de justicia, lo que tiene razón suficiente.

Esa es la razón, por la que quien deba juzgar a la luz de las previsiones de los dos primeros artículos del CCyCN, cuenta con diversas vías y métodos que le pueden prestar auxilio, como ser los principios y valores jurídicos, el elemento gramatical, exegético, lógico formal, teleológico y empírico dialéctico entre otros.

El codificador está acentuando que los principios y valores jurídicos revisten carácter normativo. Subrayo el verbo acentuar, porque en rigor de verdad participan de esa características, con independencia del reconocimiento positivo.

Es por ello que respecto a la razonabilidad, a la hora de interpretar y buscar la pauta jurídica conforme a la cual solucionar un conflicto de pretensiones, no sólo debe recurrirse a reglas formales, sino también a los principios y valores jurídicos, más allá de su positivización. Aunque cabe reconocer que en materia del derecho del trabajo, la mayoría de los principios se han convertido en mandatos legales.

Es indiscutible que el mismo código civil y comercial de la nación acepta que el derecho no está formado sólo por “reglas” sino también por “principios”.

Ello permite aseverar que las reglas (en este caso, el art. 92 bis de la LCT) deben interpretarse de manera conjunta con los principios aplicables al caso, como ser: principio protectorio (art. 14 bis de la Constitución Nacional), principio de conservación del empleo (art. 10 de la LCT), principio de buena fe (art. 63 de la LCT) y principio de solidaridad (art. 62 de la LCT), entre otros.

Estos principios, no son meras directrices o líneas orientadoras. Son verdaderos mandatos de optimización, tal como enseña Robert Alexy (Alexy, Robert, Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica, en Doxa, N° 5, año 1988).

Son mandatos de optimización porque mandan la mejor conducta posible, según sus posibilidades fácticas y jurídicas. Es decir que la judicatura del trabajo al resolver conflictos de intereses debe procurar que en la sentencia se materialicen como resultado los principios que informan la disciplina.

Es decir, el intérprete nunca opera con una norma aislada, sino que en realidad en su tarea se hace siempre presente la totalidad del ordenamiento jurídico.

Fecha de firma: 30/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ETHEL FERDMAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GABRIEL DE VEDIA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE ALEJANDRO SUDERA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIANA CASCELLI, SECRETARIA DE CAMARA



#34605535#410006798#20240430123506594

USO OFICIAL

Esto es así, dado que la admisión de los principios amplía notablemente la capacidad de respuesta del ordenamiento jurídico, en aras de obtener el resultado que más se aproxime al valor justicia.

En base a las consideraciones expresadas, la solución del caso no puede efectuarse desde una interpretación aislada, sesgada o rígida, sin considerar todo el plexo jurídico que informa el derecho laboral y que se encuentra también plasmado en normas jurídicas expresas.

También exige una mirada de la carga probatoria más amplia que el estricto rigor formal.

Desde esa perspectiva se puede observar que la patronal no produjo prueba alguna que eclipse las ya referenciadas, de manera tal que se justifique la aplicación del art. 92 bis, que le permita poner fin al contrato de trabajo, a pesar que el señor R. se encontraba de baja transitoria por un accidente de trabajo.

Resulta claro, que el actor sufrió un accidente de trabajo y sin tener aun el alta médica fue despedido con fundamento de estar dentro del período de prueba.

Ello me lleva – en uso de las facultades de la sana crítica- a considerar que la empleadora puso fin a la relación de trabajo mantenida con un trabajador que había padecido un accidente de trabajo.

Poner fin a un vínculo como consecuencia de un accidente de trabajo es –a mi criterio- un claro presupuesto de discriminación fundado en la condición psicofísica del trabajador.

Por lo tanto, la situación se encuentra alcanzada por las disposiciones de la ley 23.592, art. 1, 17 de la LCT, normas y tratados internacionales con jerarquía constitucional y convenios de la O.I.T. que prohíben todo tipo de discriminación y, en especial, en el trabajo (arts. 14 Bis, 16, 19 y 75 inc. 23 C.N.; así como del art. 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 1, 2, 7 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 1, 11 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 2, 3 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; arts. 2, 3, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, fundamentalmente los arts. 1 y 5; la Convención contra la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; la Convención sobre los Derechos del Niño, arts. 1 y 2; la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, arts. 1 y 2; y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes; y de los Convenios de la O.I.T. Nro. 100 y 111; entre otros).

El concepto de discriminación debe ser entendido de manera amplia y evolutiva, por lo que las soluciones previstas en la ley deben ceder al amparo de normas de jerarquía superior como las precedentemente citadas.

En ese temperamento, el distracto devino incausado, injustificado,

disculmatorio y en definitiva arbitrario (cfr art. 245 LCT).

Firmado por: BEATRIZ ETHEL FERDMAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GABRIEL DE VEDIA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE ALEJANDRO SUDERA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JULIANA CASCELLI, SECRETARIA DE CAMARA





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Expte. nº 3540/2020

Desde dicha óptica, será el reclamante quien deberá en primer término demostrar o aportar indicios suficientes que el acto lesiona su derecho fundamental y una vez configurado el cuadro indiciario, recae sobre la empleadora la carga de acreditar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la invocada vulneración de derechos fundamentales (Cfr "Parra Vera Máxima c/San Timoteo SA" CNAT Sala V del 14 de junio de 2006; "Arecco, Maximiliano c/ Praxair Argentina SA" Sala V del 21 de diciembre de 2006; "Alvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud SA" Sala II del 25 de junio de 2007; "Olguin Pedro Marcelo c/ Rutas del Sur SA" Sala IV del 19 de marzo de 2010; "Muñoz Carballo Alejandra Noelia c/ Casino Buenos Aires SA Compañía de Inversiones en Entretenimientos SA UTE" Sala X del 30 de abril de 2010, entre muchos otros).

Este es el criterio que luego fuera auspiciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación *in re* "Pellicori, Liliana Silvia c/Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo" (sentencia del 15/11/2011, P.489, XLIV), al sostener que *“la cuestión de los medios procesales destinados a la protección y, en su caso, reparación de los derechos y libertades humanos se erigió siempre como uno de los capítulos fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (...) no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que sean efectivos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Acosta Calderón vs. Ecuador, sentencia del 24 de junio de 2005, Serie C Nº 129, parr. 93). Normas constitucionales y supralegales han señalado la necesidad de que el diseño y las modalidades con que han de ser reguladas las garantías y ciertamente su interpretación y aplicación deben atender y adecuarse a las exigencias de protección efectiva que específicamente formule cada uno de los derechos humanos, derivadas de los caracteres y naturaleza de estos y de la concreta realidad que los rodea, siempre, por cierto, dentro del respeto de los postulados del debido proceso. Asimismo ponen de relieve los serios inconvenientes probatorios que regularmente pesan sobre las presuntas víctimas, nada menos que en litigios que ponen en la liza el ominoso flagelo de la discriminación, cuya prohibición inviste el carácter de ius cogens. Así, resultara suficiente para la parte que afirma haber sido discriminada con la acreditación de hechos que prima facie evaluados resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual, corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que este tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. La evaluación de uno y otro extremo, naturalmente, es cometido propio de los jueces de la causa, a ser cumplido de conformidad con las reglas de la sana crítica. La doctrina del Tribunal no supone la eximición de prueba a la parte que tilda de discriminatorio a un acto, pues de ser esto controvertido, pesa sobre aquélla la carga de acreditar los hechos de los que verosíblemente se siga la configuración del motivo debatido”* (cfr. Considerandos 11 y 12 del precedente citado).

USO OFICIAL



Es así, que en relación con la mecánica probatoria en este tipo de causas, se ha sostenido en un criterio que comparto que *“no corresponde exigir al trabajador plena prueba del motivo discriminatorio, bastando a tal efecto los indicios suficientes (art. 163, inc. 5 del CPCCN). Por tal motivo es que en el reparto de cargas procesales, a cargo de la empleadora deberá colocarse la justificación de que el acto obedece a otros motivos. No implica lo expuesto, desconocer el principio contenido en el artículo 377 de la norma citada, ni lo específicamente dispuesto en la ley 23.592, ya que “(...) quien se considere afectado en razón de cualquiera de las causales previstas en esta ley (raza, nacionalidad, opinión política o gremial, sexo, caracteres físicos, etc.) deberá en primer lugar, demostrar poseer las características que considera motivantes del acto que ataca (...) y los elementos de hecho, o en su caso, la suma de indicios de carácter objetivo en los que funda la ilicitud de éste, quedando en cabeza del empleador acreditar que el despido tuvo por causa una motivación distinta y a su vez excluyente, por su índole, de la animosidad alegada (...)”*.

A tal efecto, vale destacar el concepto y desarrollo en nuestro ordenamiento vigente de la carga dinámica de la prueba, con recepción legal, luego de muchos años de aplicación pretoriana y de predicamento doctrinario

El Código Civil y Comercial de la Nación en su art. 1734, define la distribución de la carga de la prueba siguiendo la tradicional línea del *onus probandi* adoptada en el art. 377 del Cód. Procesal Civil de la Nación.

Se trata de una norma de naturaleza procesal inserta en el Código de fondo.

En dicha legislación se regula que, la carga de la prueba incumbe a quien afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que la jurisdicción no tenga el deber de conocer. Dado que cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.

El artículo 377 del Código Procesal, fija como regla general, que la carga probatoria de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien los invoca, con excepción de que exista una disposición legal en sentido contrario.

Por lo demás, acreditar la configuración del factor de atribución para endilgar la responsabilidad indemnizatoria, sea objetivo o subjetivo, está a cargo de quien reclama el resarcimiento del daño padecido.

En sentido contrario, quien alega la existencia de una causal de eximición de responsabilidad deberá demostrar los hechos en los cuales la sustenta, especialmente cuando el factor de atribución es objetivo y definido por la ley que invierte la principal carga probatoria, poniendo en cabeza del imputado, el deber procesal de acreditar la causal que lo exime de responsabilidad.

En palabras de la Dra. Analía Victoria Romero, *“(l)a distribución de la carga de la prueba puede ser vista como un problema de la dogmática procesal, atinente a*

Fecha de firma: 10/04/2024 *l) a distribución de las partes en el proceso. También puede ser vista como un tema de Derecho*

Firmado por: BEATRIZ ETHEL FERDMAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GABRIEL DE VEDIA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE ALEJANDRO SUDERA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIANA CASCELLI, SECRETARIA DE CAMARA



#34605535#410006798#20240430123506594



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Expte. nº 3540/2020

Privado que establece reglas de juzgamiento ante la insuficiencia demostrativa. Se trata de analizar la cuestión desde una perspectiva que toma en cuenta el riesgo de probar y su distribución, como así también su diferencia de otros riesgos que asumen las partes en la relación jurídica, a fin de no confundirlos.” (“Distribución de la carga probatoria y cargas probatorias dinámicas (art. 1735 del C. C y Comercial)” – Artículo recuperado del enlace electrónico <http://www.amfjn.org.ar/2018/08/03/distribucion-de-la-carga-probatoria-y-cargas-probatorias-dinamicas-art-1735-del-c-c-y-comercial/>).

Al respecto del primer enfoque, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece en su artículo 61 que: “*A pedido de parte, el juez abrirá la causa a prueba, o dispondrá su producción según correspondiere conforme al tipo de proceso; en su caso, podrá mandar practicar las medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad de los hechos autorizadas por este Código*”.

De este modo, si bien es claro que el *onus probandi* cae en cabeza de las partes del proceso judicial, se destacan las facultades ordenatorias e instructorias que emanan del artículo 34 del mismo cuerpo normativo, y colocan al juzgador como el verdadero administrador del proceso.

En cuanto a la distribución inicial de la carga probatoria, su artículo 377 dispone que incumbirá “*(...) a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción (...).*”

En consonancia con tal premisa, el mencionado artículo 1734 del Código Civil y Comercial de la Nación, al manifestar que “*(e)xcepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien los alega.*”

Sin embargo, la norma siguiente en el articulado reza: “*Artículo 1735.- Facultades judiciales. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa*”.

Esta corriente de pensamiento jurídico abrevia en el análisis realizado por Jeremías Bentham, quien sostuvo que: “*La carga de la prueba debe ser impuesta, en cada caso concreto, a aquella de las partes que la pueda aportar con menos inconvenientes, es decir, con menos dilaciones, vejámenes y gastos*” (Bentham, Jérémie; Tratado de las pruebas judiciales; trad. de la obra; Traité des Preuve Judiciaires, Bossange Frères, Paris, 1823, por Manuel Ossorio Florit, Ed. Ejea, Bs. As, 1971, vol. II, p. 149).

USO OFICIAL



En este sentido, la doctrina y el mandato legal de la carga probatoria dinámica propugna, en la República Argentina, su adjudicación a la parte en mejores condiciones de probar los hechos controvertidos. Así, el significado de “mejor” se relaciona con la más eficiente, en el sentido de que a quien ya tiene la información o la prueba le resulta más sencillo aportarla al proceso.

Detrás de la instrumentación formal de un despido sin causa hay siempre un motivo o hecho detonante real que promueve la decisión de romper el vínculo.

Resultan ilustrativas las palabras del colega Roberto Pompa al señalar que *“en general los supuestos de discriminación no se producen “a la luz del día”, es decir nadie va a admitir que discriminó, sino que aparecen solapados, a veces utilizándose otras figuras o situaciones que persiguen encubrir situaciones de discriminación. Si esta es la realidad, en función de ese mismo principio debe aceptarse la tesis que propicia en esta materia la producción dinámica de la prueba, como la inversión de la carga probatoria luego de aportarse indicios que permitan tener por presuntamente configuradas situaciones de discriminación (cfr. Roberto C. Pompa, “Nulidad del despido discriminatorio. En camino a su consolidación”, Revista La Causa Laboral N° 41, p. 11).*

En definitiva, al no haber la demandada acreditado razones que superen a las de su contrincante, que llevaron a extinguir el vínculo y comprobado por el actor como indicio notorio y suficiente que se trató de un despido discriminatorio, se impone la inversión de la carga de la prueba para demostrar que no lo fue.

Sin embargo la patronal no lo ha logrado comprobar.

Si bien es cierto, que el ordenamiento legal prevé la figura del período de prueba como una facultad de la que pueden valerse las empleadoras para poner fin al vínculo cuando observan que la contratación efectiva y permanente de un trabajador no es conveniente a los fines de la empresa, no debe dejar se afirmarse que no corresponde abusar de tal figura, en situaciones de licencia ante accidente de trabajo.

En todo caso, el art. 92 bis de la LCT, no autoriza a la empleadora a ejercer tales facultades si el trabajador se halla de baja médica por causa de accidente de trabajo.

Ello se debe, a que las facultades que le otorga el art. 92 bis deben ceder frente a la tutela de derechos más altos consagrados por ordenamientos constitucionales, supralegales y de los tratados internacionales que prohíben toda forma de discriminación como ya lo he señalado.

De esta manera, el principio de no discriminación se erige como una valla infranqueable a las facultades y poderes de la empleadora.

Ahora bien, en el caso particular de las presentes actuaciones, surge que el actor no cuestionó la validez del ordenamiento que rige el instituto del período de prueba, por lo que siendo que a los jueces les corresponde la aplicación del derecho, teniendo en cuenta el amplio abanico de reclamos formulados en la demanda y que la protección ante el despido arbitrario frente a la discriminación son de raigambre constitucional, aplicaré la

Conclusiones que reitero, para el caso particular de autos, considero más justa y adecuada de

Firmado por: BEATRIZ ETHEL FERDMAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GABRIEL DE VEDIA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JOSE ALEJANDRO SUDERA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JULIANA CASCELLI, SECRETARIA DE CAMARA





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Expte. nº 3540/2020

acuerdo al “*iura novit curia*”, que aprecio en el pago de una indemnización por el despido discriminatorio.

Dicho resarcimiento, lo establezco en una suma equivalente a 13 salarios por ser ésta la solución que el sistema de la LCT adopta para los casos de despido discriminatorio como son los regulados por los arts. 178 y 182 de la LCT y que, en el caso concreto de autos, asciende a la suma de \$407.494,49 (que surge de computar la remuneración mensual de \$31.345,73 determinada por la Sra. juez de grado en base a lo informado en la pericial contable) y que difiero a condena.

En virtud de lo expuesto, propicio hacer lugar el agravio en examen y revocar este aspecto de la sentencia.

3.- En referencia al primer agravio de la demandada, en cuanto intenta cuestionar la procedencia de las indemnizaciones, entiendo que reviste el carácter de desierto.

Ello es así, por cuanto se impone destacar que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, expresando argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, invocando aquella prueba cuya valoración se considera desacertada o poniendo de manifiesto la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art. 116 L.O.), debiéndose demostrar, punto por punto, la existencia de errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el juzgador y la indicación precisa de las pruebas y de las normas jurídicas que el recurrente estime que le asisten.

Sin embargo, tales extremos no se advierten satisfechos con las dogmáticas alegaciones contenidas en el escrito que se analiza, las que se muestran como una posición en discrepancia con el resultado adverso de la sentencia.

Ello conduce a reputar desierto los agravios aquí analizados.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que corresponde declarar desierto el recurso de apelación si el escrito de expresión de agravios no formula una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollados por la sentenciante de la anterior instancia, desde que las razones expuestas en el memorial respectivo deben ser suficientes para refutar los argumentos de hecho y de derecho dados para arribar a la decisión impugnada; no bastando en consecuencia escuetos argumentos que no constituyen más que una mera discrepancia con el criterio sostenido en el fallo recurrido y que distan de contener una crítica concreta y razonada de los argumentos que sostienen a aquél (conf. Fallos: 315:689; 316:157).

La crítica supone un análisis de la sentencia mediante raciocinios que demuestren el error técnico, la incongruencia normativa o la contradicción lógica de la ~~relación de los hechos que la judicatura considera conducentes~~ para la justa composición

Fecha de firma: 30/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ETHEL FERDMAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GABRIEL DE VEDIA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE ALEJANDRO SUDERA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIANA CASCELLI, SECRETARIA DE CAMARA



#34605535#410006798#20240430123506594

USO OFICIAL

del litigio, de su calificación jurídica y de los fundamentos de derecho que sustentan su decisión.

Por ello, la ley adjetiva exige que esa crítica sea razonada. Es decir que la apelante refute las conclusiones que considera erradas, requisito que, en estos agravios, no se encuentra cumplido.

Desde tal perspectiva de análisis, no encuentro razones para apartarme de lo resuelto por la magistrada que me precedió (cfr. arts. 386 y 477 C.P.C.C.N.) por lo que propongo desestimar las objeciones formuladas al respecto en este punto.

En definitiva, en torno a estas temáticas, concluyo que la decisión de grado arriba firme a esta instancia pues, como se dijo, la recurrente no efectúa una crítica concreta y razonada en los términos del art. 116 L.O., lo que conduce a declarar desierto este agravio en análisis y, en consecuencia, confirmar la decisión de grado.

4.- Lo propuesto, también me lleva a confirmar el fallo en cuanto condena al incremento previsto en el art. 2 de la Ley 25.323, toda vez que el actor intimó el pago de las indemnizaciones y debió iniciar el presente juicio para obtener el cobro de su crédito.

En efecto, el art. 2 de la ley 25.323, establece un incremento del 50% en las indemnizaciones previstas por los artículos 232, 233 y 245 de la LCT. -indemnización sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido e indemnización por antigüedad- y arts. 6 y 7 de la ley 25013 -preaviso e indemnización por antigüedad- (o las que en el futuro las reemplacen), cuando el empleador fehacientemente intimado por el trabajador no las pagare y en consecuencia lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio.

El objetivo perseguido, es compeler al empleador a pagar en tiempo y forma las indemnizaciones por despido y evitar litigios. El presupuesto de procedencia es el no pago de la indemnización en tiempo oportuno y la existencia de un despido sin invocación de causa producido a partir del 20/10/2000, aunque se debe hacer extensivo a los casos de despido indirecto con una causa justificada y de despido directo con invocación de una causa a todas luces inverosímil.

El caso, se trata de un despido arbitrario e injustificado.

Así, el actor se vio obligado a interponer la presente acción para el reconocimiento de sus derechos sobre la indemnización que consideró que le correspondía, ante la injuria que le ocasionó la actitud de la empleadora.

En ese temperamento, entiendo que corresponde receptar la multa del artículo 2º de la ley 25.323, debido a que el actor intimó al pago de indemnizaciones por despido y ante renuencia de la demandada, debió iniciar acciones legales para su cobro.

En virtud de ello, corresponde rechazar este agravio y confirmar el punto en análisis.

5.- A su vez, la demandada se agravia de la condena al pago de la multa del art. 80 LCT esgrimiendo que los certificados fueron puestos a disposición del señor R.





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Expte. nº 3540/2020

Esgrime que los certificados del art. 80 de la LCT siempre estuvieron a disposición del actor.

Al respecto la sentencia en crisis concluyó que: "...Respecto a la multa del art. 45 Ley 25345, se impone acogerla en forma favorable, teniendo en consideración que el actor intimó en procura de la entrega del certificado de trabajo en los términos del art. 3 Decreto 146/01 – ver telegrama de fecha 14 de mayo de 2019 citado -, sin que se acredite por parte de la empleadora el cumplimiento de tal obligación. En cuanto al pedido de entrega de dichos certificados, cabe hacer lugar a los mismos, bajo apercibimiento de astreintes (art. 80 LCT)...".

La queja resulta improcedente, debido a que de las constancias de marras se desprende que el accionante intimó sin resultado alguno a la empleadora de acuerdo a la manda legal.

Asimismo no se advierte que de la lectura de autos surja que la empleadora haya acreditado la no concurrencia de la trabajadora con la finalidad de recibir el certificado de trabajo, ni que la falta de entrega de esa documentación haya obedecido a la negativa de este último.

La “puesta a disposición” de los certificados no basta por sí sola en el presente caso para configurar la mora de no acreditar la no concurrencia de la trabajadora a recibirlos con posterioridad a la mencionada interpelación.

Por otra parte, “poner a disposición” no es sino una mera exteriorización de la voluntad que sólo traduce una actitud frente a un acontecer que no escapa a la mera subjetividad, no pudiendo, por tanto, alcanzar a producir los efectos de una “intimación” que, como tal, importe condicionar el comportamiento del acreedor que se ve obligado a adoptar su conducta a los lineamientos que le fija el deudor, imponiéndole de tal manera asumir un proceder activo frente a la reclamación formulada (cfr. C.N.A.T., Sala VII, Sent. Nº 12.340 del 26/12/86, “Cáceres Héctor c/Volkswagen Argentina S.A.”).

En la especie, no puede considerarse cumplida la intimación a acompañar las certificaciones del art. 80 LCT, con la sola respuesta de su puesta a disposición, pues la empleadora siempre tiene el recurso legal de la consignación.

Por lo tanto, resulta irrelevante la circunstancia que la demandada los hubiera puesto a su disposición, o bien, los acompañara recién al contestar la demanda, pues la entrega de los certificados de trabajo y aportes previsionales al dependiente en oportunidad de la extinción de la relación laboral, es una obligación a su cargo, que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación.

No hay razones para considerar que el cumplimiento de esta obligación dependa –en lo que se refiere a su aspecto temporal- que el trabajador concurra a la sede de la empresa a retirar los certificados, sino que corresponde entender que, en caso que así no ocurra, el empleador debe, previa intimación, consignarlos judicialmente.

Fecha de firma: 30/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ETHEL FERDMAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GABRIEL DE VEDIA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE ALEJANDRO SUDERA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIANA CASCELLI, SECRETARIA DE CAMARA



#34605535#410006798#20240430123506594

USO OFICIAL

Además, cabe explicitar que no obstante el hecho que la empleadora haya puesto a disposición del trabajador las certificaciones contempladas por el art. 80 LCT primer párrafo al ser requerida en tal sentido, no puede sustraerse al pago del resarcimiento establecido en el párrafo agregado por el art. 45 de la ley 25.345 si los instrumentos no reflejan los reales datos de la relación con respecto a la incidencia de las horas extra en la remuneración mensual.

En orden al agravio de imposición de *astreintes*, lo cierto es que al estar pendiente el cumplimiento de la entrega del certificado de trabajo por parte de la recurrente y atento a que el fundamento de la aplicación de la sanción conminatoria radica en coaccionar a la deudora, corresponde el apercibimiento determinado en grado en los términos del art. 804 del C.C.C.N.

Como corolario de la evaluación de este agravio de la demandada, corresponde desestimarlos y confirmar la decisión en torno del art. 80 LCT, dispuesta en la sentencia de grado.

En definitiva, en función de lo expuesto el capital de condena queda determinado en la suma de **\$527.000,07**.

6.- Plantea la accionada la inconstitucionalidad de la actualización dispuesta por las actas CNAT N° 2601, 2630, 2658 y 2764.

Cuestiona los intereses dispuestos en origen, en base al sistema de capitalización anual previsto en el acta CNAT 2764. Invoca la inconstitucionalidad de la norma del art. 770 inc. b) del CCyCN, al entender que adoptar tal criterio conlleva una desmesurada consecuencia patrimonial sobre el patrimonio de su mandante y que genera un enriquecimiento sin causa justificada en favor del trabajador.

Aduce por lo demás, que el Código Civil y Comercial de la Nación vigente ratifica como regla general la prohibición del anatocismo, esto es, que no “*se deben intereses de los intereses*”. Arguye en tal sentido, que en la interpretación judicial debe primar un criterio muy restrictivo para aplicar ese supuesto de anatocismo y que, en su caso, de admitirse debería aplicar la capitalización una sola vez. Destaca que la adopción de ello vulnera su derecho constitucional de propiedad y de la defensa en juicio, conforme consideraciones que vierte.

En este sentido, si bien no soslayo que la recurrente invoca la inconstitucionalidad de la norma del art. 770 inc. b del CCyCN, pues el anatocismo decidido veda el orden público y altera en forma relevante los derechos del deudor que, al duplicar la pretensa indemnización, afecta su derecho de propiedad y de defensa en juicio, debo decir que no comparto las manifestaciones vertidas por el apelante respecto a la inconstitucionalidad de la norma del art. 770 inc. b antes referida.

Primero porque no aparece expuesto ningún elemento objetivo que demuestre que la aplicación de la norma en cuestión conlleve a una desmesurada consecuencia patrimonial sobre el patrimonio de la aseguradora que cause un perjuicio o agravio en el





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Expte. nº 3540/2020

caso concreto al apelante. El sistema de capitalización que se sustentó en la norma del art. 770 no es más que el que rige en el sistema financiero del país.

Segundo, porque es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptible de encomendarse a un Tribunal de Justicia, siendo un acto de suma gravedad institucional y que debe considerarse como “*ultima ratio*” del orden jurídico, de tal forma que únicamente debe recurrirse a ella cuando una estricta necesidad así lo requiera (Fallos, 264:51; 285: 322; 300: 1041 y 308:647 entre muchos otros) a la que sólo corresponde llegar una vez establecida su contradicción con los preceptos de la Ley fundamental (Fallos 296:117) y luego de haber demostrado el agravio en el caso concreto (Fallos, 302:166).

Nuestro más Alto Tribunal ha declarado que todo planteo debe ser explícito e inequívoco, requiriéndose no sólo la mención de las cláusulas constitucionales que estime vulneradas, sino la demostración pertinente (Fallos, 293:323; 296:124; 302:326, entre otros).

Ello supone que el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta le causa un perjuicio y debe probar, además que ello ocurre en el caso concreto (Fallos, 310:217), situación que no se verifica en autos y que sella la suerte adversa del planteo vertido por la recurrente.

Sentado ello, cabe poner de relieve que el anatocismo es la operación por la cual los intereses ya devengados son capitalizados al vencimiento de un período determinado, circunstancia que reitero, aparece en cualquier operación bancaria utilizada en la actualidad.

En este sentido, el Código Civil y Comercial vigente si bien ha ratificado como regla general la prohibición del anatocismo, lo cierto es que expresamente incluyó una serie de excepciones a la regla general que permite la capitalización de intereses (cfr. art. 770 CCyCN).

Así los incisos b) y c) del referido art. 770 distinguen dos eventuales momentos que la prolongación de la mora del deudor autoriza a capitalizar los intereses devengados a tales eventos, ellos son la notificación de la demanda y la orden judicial de pago de la deuda líquida. En el primer caso, supone una deuda, que viene devengando intereses y que fue reclamada judicialmente. El segundo, una sentencia que mande a pagar la deuda, si el deudor sostiene su contumacia respecto del pago, para lo cual debe mediar intimación y esta no ser atendida por parte del deudor.

Entiendo que la modificación que introduce el art. 770 CCyCN es una mejora en cuanto a su precedente del Código Civil, dado que establece en su inc. b) que cuando la obligación se demande judicialmente, la acumulación opera en principio desde la ~~fecha de la notificación de la demanda~~, cuestión que por otro lado, fue abordada por la

Fecha de firma: 30/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ETHEL FERDMAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GABRIEL DE VEDIA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE ALEJANDRO SUDERA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIANA CASCELLI, SECRETARIA DE CAMARA



#34605535#410006798#20240430123506594

USO OFICIAL

CSJN en el “Recurso Queja N° 1 - [OLIVA](#), FABIO OMAR c/ COMA S.A. s/despido”, expte. CNT 023403/2016/1/RH001 (Fallos: 347:100),

Zanjado ello, cabe destacar que el 13 y 14 de marzo de 2024 en acuerdo de mayoría de CNAT -en base a la resolución nro. 3- se acordó reemplazar el acta nro. 2764 del 07/09/2022 por el acta nro. 2783, en la cual se decidió adecuar los créditos laborales, que no se rijan por un régimen legal de intereses, de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) reglamentada por el BCRA más una tasa pura del 6% anual en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago, con más una única capitalización conforme el art. 770 inc. b CCyCN que se aplicará en la fecha en que se produzca la notificación de la demanda exclusivamente sobre la tasa pura del 6% anual (cfr. resolución de Cámara nro. 3 y acta 2783).

Ello en función de los fundamentos vertidos por la CSJN en los distintos pronunciamientos que se dieron a lo largo de quince años, esto es el caso “ [Massolo](#)” del 20/04/2010 (Fallos: 333:447), a propósito de la prohibición de indexar instituida por el artículo 7 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561; “Puente Olivera, Mariano c/ Tizado Patagonia Bienes Raíces del Sur SRL s/ despido”, del 08/11/2016 (Fallos: 339:1583); “Romero, Juan Antonio y otros c/ EN -Ministerio de Economía- y otro s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 08/12/2018 (Fallos: 341:1975) y en particular, lo expresado en el caso “García, Javier Omar y otro c/ UGOFE S.A. y otros s/ daños y perjuicios” (Fallos: 346:143), donde el Alto Tribunal descalificó una sentencia de la Cámara Nacional en lo Civil que había ordenado aplicar una tasa de interés multiplicada, aseverando que la metodología no se ajustaba a los criterios previstos por el legislador en el artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Sin embargo, al dejarse sin efecto el sistema de capitalización anual previsto en el acta CNAT 2764 –cfr. lo expuesto previamente- las tasas de interés contempladas en las actas de años anteriores –nros. 2601, 2630 y 2658- resultan a todas luces insuficiente para proteger el crédito alimentario del trabajador–acreedor, si se tiene en cuenta las variaciones económicas y parámetros inflacionarios medidos por el INDEC.

Este Tribunal reiteradamente sostuvo que la merma que el valor de los créditos de los trabajadores sufre por la demora y aún más por la mora en su reconocimiento y su consecuente pago, debe ser conjurado por los jueces mediante el uso adecuado de una tasa de interés en los términos indicados previamente. El objetivo es mantener en lo posible el valor de la indemnización debida de carácter alimentario frente al deterioro del signo monetario y compensar al acreedor de los efectos de la privación del capital por la demora del deudor. Por ello, cuando la tasa de interés aplicada por los Tribunales refleja el costo del dinero por operaciones de mercado realmente existentes, no hay agravio constitucional alguno.

Por ello y teniendo en cuenta lo dispuesto por los arts. 767 y 768 CCyCN, es materia discrecional de los jueces, aplicar las tasas de interés bancaria vigente según

Fecha de firma: 30/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ETHEL FERDMAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GABRIEL DE VEDIA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE ALEJANDRO SUDERA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIANA CASCELLI, SECRETARIA DE CAMARA



#34605535#410006798#20240430123506594



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Expte. nº 3540/2020

reglamentación del BCRA (cfr. inc. c art. 768 CCyCN), prerrogativa -a su vez- reconocida por la Corte en la referida causa ‘Oliva’.

No obstante ello, ante la ausencia de agravio de la parte actora sobre este punto, no es posible tornar más gravosa la situación del único apelante en el mencionado aspecto, pues de lo contrario, se incurriría en una indebida *reformatio in pejus*, que tiene jerarquía constitucional, al colocar a la única apelante en peor situación que la resultante del pronunciamiento recurrido. Ello determinaría una violación en forma directa e inmediata de las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio (CSJN, Fallos: 332:523; 332: 892, entre muchos otros).

En ese contexto y a fin de no fallar “*in pejus*” para la apelante ni dejar desprotegido ni licuado el crédito alimentario del trabajador, corresponderá aplicar la tasa CER y los intereses contemplados en el Acta 2783, CNAT, pero acotando el resultado económico al monto que resulte de aplicar el método de cálculo dispuesto en la instancia anterior con una reducción del 20% la que se efectuará sobre el total del capital revalorizado con más sus accesorios, esto último en uso de las facultades conferidas por el art. 771, C.C. y C.N. (conforme doctrina fallo “*Oliva*”).

7.- La solución propuesta implica adecuar la imposición de costas y regulación de honorarios de primera instancia (conf. art. 279 del C.P.C.C.N.) y proceder a su determinación en forma originaria, lo que torna abstracto los agravios introducidos en este aspecto.

Las costas de ambas instancias sugiero imponerlas a cargo de la demandada vencida en lo substancial (conf. art. 68 del C.P.C.C.N.). Asimismo, en lo que respecta a los honorarios por los trabajos cumplidos en la sede de origen se regulan de la siguiente forma: para la representación letrada del actor en 19,30 UMA (equivalente a \$783.020,30); para su similar de la demandada en 14,47 UMA (equivalente a \$587.062,37) y para el perito contador en 12,50 UMA (equivalente a \$507.137,5).

8.- Por los trabajos cumplidos ante esta alzada, se le regulan a las representaciones letradas intervinientes, el 30% de lo que en definitiva les corresponda por sus labores en la sede anterior (LA).

La Doctora **BEATRIZ E. FERDMAN** manifestó:

I. Adelanto que he de disentir con la solución propuesta por mi colega preopinante en función de las consideraciones que efectuaré seguidamente respecto a la existencia de un despido discriminatorio.

Si bien coincido con el Dr. de Vedia en cuanto no corresponde caer en consideraciones meramente teóricas de las fórmulas legislativas, lo cierto es que ante un planteo de discriminación -por cualquier causa- debe acreditarse indicios que tornen verosímil el reclamo.

USO OFICIAL



En el presente caso, es de destacar que el actor mientras cursaba el período de prueba sufrió un accidente laboral, cuestión que arriba firme a esta Alzada. Lo que se discute es la posibilidad que el actor hubiese sido despedido en forma discriminatoria por el hecho súbito y violento que generó la licencia médica otorgada.

El primer escollo en el análisis es que la ruptura del contrato de trabajo ocurrió en base a un supuesto legal particular, como es el art. 92 bis LCT. El principio general indica que el contrato de trabajo será por tiempo indeterminado, a excepción de lo dispuesto por el art. 96, donde los primeros tres meses, el trabajador estará a prueba. Dentro de ese período de tres meses, puede extinguirse la relación *sin expresión de causa, sin derecho a indemnización*, no obstante la subsistencia de deberes y obligaciones respecto a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo (inc. 6). La obligación que recae en cabeza de quien extinga la relación en este período particular, es la de preavisar según lo establecido en los artículos 231 y 232.

Al tratarse de una excepción que habilita la norma, esto es, extinguir la relación laboral sin expresión de causa y sin derecho a indemnización en tanto no se configura incumplimiento alguno, debe acreditarse indiciariamente la existencia de una causa discriminatoria.

Es cierto que tal como lo sostiene la doctrina y jurisprudencia mayoritaria con criterio que comparto, lo dificultoso del tema está dado por la carga probatoria; por ello resulta suficiente para la parte que afirma haber sido discriminada, acreditar hechos que *prima facie* evaluados sean idóneos para inducir su existencia, caso en el cual, se invertirá la carga probatoria y será el demandado quien deba demostrar que su accionar se vio motivado objetiva y razonablemente en un hecho ajeno a toda discriminación (cfr. doctrina de la CSJN en “*Pellicori, Liliana Silvia c. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ Amparo*” -sentencia del 15 de noviembre de 2011-)

Pero si el peticionante no expone un indicio que torne verosímil la existencia de una conducta prohibida o la de un factor de atribución adecuado que habilite el análisis de hechos ocurridos como desencadenantes de una acción discriminatoria, no debe invertirse la carga probatoria, máxime cuando la acción rupturista se inserta dentro de la estructura normativa que así lo habilita. La doctrina del Alto Tribunal antes citada no supone la eximición de prueba a la parte que tilda de discriminatorio un acto, pues de ser esto controvertido, “*pesa sobre aquélla la carga de acreditar los hechos de los que verosímilmente se siga la configuración del motivo debatido*” (cfr. considerandos 11 y 12 del precedente citado y reiterado en la causa “Sisnero” (Fallos: 337: 611) y “Varela” (CSJ 528/2011 del - 04/09/2018))

En este contexto, para verificar si existe discriminación debe analizarse si las conductas atribuidas a la demandada obedecieron a una restricción, alteración o exclusión por algún aspecto vinculado a una condición subjetiva y cuya finalidad fue el menoscabo o supresión de los derechos fundamentales. Pero la evaluación de uno y otro extremo, es

Fecha de firma: 09/09/2024 C. M. Q. T. Q. propio de los jueces de la causa.

Firmado por: BEATRIZ ETHEL FERDMAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GABRIEL DE VEDIA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE ALEJANDRO SUDERA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIANA CASCELLI, SECRETARIA DE CAMARA



#34605535#410006798#20240430123506594



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Expte. nº 3540/2020

En el caso, no encuentro configuración de indicios que me permitan concluir que el actor hubiere sido discriminado por motivos de salud o por haber padecido un accidente de trabajo (cfr. arts. 17 y 1 de la ley 23.592), pues los hechos narrados no son concluyentes en tal sentido, pues reitero, en este caso, siquiera puede considerar una situación de desproporcionalidad, irrazonabilidad o arbitrariedad en la medida de la ruptura, ya que es un supuesto contemplado expresamente por la norma del art. 92 bis LCT.

No soslayo el señalamiento que hace mi colega respecto a la negativa que manifestó la demandada en relación con el accidente sufrido. Sin embargo, cabe destacar que ello por sí solo no genera a mi parecer, un indicio que permita inferir el ocultamiento de una conducta discriminatoria hacia el trabajador.

De hecho, destaco que en momento alguno el peticionante delimita la supuesta discriminación por motivos del accidente sufrido o por las secuelas que habría dejado sobre su cuerpo o, incluso, que las secuelas hubieran generado el comienzo de una enfermedad que debía continuar con un tratamiento prolongado y que, en virtud de ello, la demandada hubiera decidido su despido, simplemente se limitó a indicar que la demandada lo despidió mientras estaba cursando una licencia por accidente laboral, obviando que además de ello, se encontraba en período de prueba donde la demandada puede extinguir el vínculo sin expresión de causa y sin indemnización.

Por ello es que no puede sostenerse siquiera indiciariamente, la existencia de conductas u omisiones atribuidos a la demandada que revelen la comisión de actos prohibidos que hubieren lesionado la dignidad e integridad moral del trabajador, por lo que considero debe rechazarse esta pretensión y confirmarse lo decidido en la anterior instancia.

II. En las demás cuestiones traídas ante esta alzada adhiero a los fundamentos dados por mi colega preopinante.

III. Los honorarios regulados en la anterior instancia a los profesionales intervinientes no resultan desajustados con relación a las tareas realizadas, su complejidad y la relevancia para la resolución de la causa, teniendo en cuenta las pautas del artículo 38 LO y las escalas arancelarias de la actividad pericial, por lo que también propicio su confirmación.

Teniendo en cuenta la forma en que se resolvió la presente causa, las costas de alzada deben ser impuestas en el orden causado (cfr. art. 68 CPCCN) y los honorarios de alzada establecen en el 30% de lo que le fuera regulado en origen (artículo 30 ley 27.423).

El doctor **ALEJANDRO SUDERA** manifestó:

La cuestión acerca de la cual disienten mis estimados colegas preopinantes no puede sino ser calificada como una situación dilemática, en tanto coloca al operador jurídico en la obligación de elegir entre dos o más opciones éticas y legales.

USO OFICIAL



Si bien no puedo sino coincidir con el análisis realizado por el Dr. de Vedia -fs. 3 a 5 de su voto- respecto de las pautas de interpretación que deben ser consideradas, no llego a la misma conclusión que él.

Previo a toda otra cuestión, quiero realizar una aclaración que no hace en esencia al fondo de la cuestión en debate, pero sí está vinculada con ella. En mi opinión el art. 92 bis LCT regula un derecho del empleador a disolver el contrato de trabajo por tiempo indeterminado (en tanto no sea de temporada) dentro de sus tres primeros meses, sin invocar causa y sin que ello le genere obligación indemnizatoria por el hecho de la ruptura. No se trata de un despido sin causa o sin justa causa, sino de un modo de disolución del contrato de trabajo distinto de esos; adviértase que el legislador bien se ha cuidado de no introducir el vocablo *despido* en la redacción del art. 92 bis LCT.

Dado que se impone la obligación de preavisar la extinción -y de indemnizar en caso de no hacerlo-, no resulta fácil considerarlo como un verdadero o puro período de prueba. Pero lo cierto es que hay acuerdo generalizado en esto último. Pero, como ya asenté renglones antes, la disolución del contrato de trabajo dispuesta por el empleador dentro de los tres primeros meses del contrato por tiempo indeterminado que constituyen *período de prueba* (porque podría darse el caso de que así no sea, como ocurre si las partes pactan su reducción o inexistencia, o cuando se vuelve a contratar a un trabajador que ya estuvo sometido a *período de prueba* con anterioridad -numeral 1- o de que no se haya registrado al trabajador -numeral 3-) sin que se devengue obligación indemnizatoria constituye un derecho del empleador.

Como ocurre generalmente, ese derecho no es absoluto sino que su ejercicio está sometido a reglas, o sea, se encuentra limitado. En casos como el sub judice, el numeral 6 del art. 92 bis LCT dispone que “*El trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del período de prueba si el empleador rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso*”. De modo tal que la cuestión dilemática a la que hice referencia al comienzo se encuentra específicamente regulada: frente al derecho del empleador a disolver el contrato sin invocación de causa y sin obligación indemnizatoria se establece el derecho del trabajador -si aquel derecho es ejercido por el empleador mientras el dependiente se encuentra gozando de una licencia “por accidente o enfermedad del trabajo”- a las prestaciones pertinentes, limitadas temporalmente por el tiempo máximo del *período de prueba*.

Con estos fundamentos, y los vertidos por la Dra. Beatriz Ferdman -que comparto- adhiero a su voto.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia definitiva en cuanto fue objeto de recursos y

Fecha de firma: 2024/12/04 conforme considerandos del segundo voto del presente acuerdo, con costas de

Firmado por: BEATRIZ ETHEL FERDMAN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GABRIEL DE VEDIA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE ALEJANDRO SUDERA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIANA CASCELLI, SECRETARIA DE CAMARA



#34605535#410006798#20240430123506594



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Expte. nº 3540/2020

Alzada en el orden causado. 2) Regular los estipendios por los trabajos cumplidos ante esta alzada por las representaciones letradas intervinientes en el 30% de lo que en definitiva les corresponda por sus trabajos en la anterior. 3) Cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

FL

Gabriel de Vedia	Beatriz E. Ferdman	José Alejandro Sudera
Juez de Cámara	Jueza de Cámara	Juez de Cámara

USO OFICIAL

